

1503675-72.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503675-72.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503675-72.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324541/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21672724 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2990/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2324541 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2990/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JERRY ALLAN DO NORTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JERRY ALLAN DO NORTE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 21h10min, na Avenida Laranjeiras, nº 1720, Vila Queiroz, na cidade e comarca de Limeira, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando 1.020,76 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado encontrava-se no interior de um carro de aplicativo, tipo Uber, onde trazia consigo entorpecente, para fins de tráfico.

Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações de que um indivíduo de nome JERRY havia ido do bairro Parque Belinha Ometo, de Uber, até a avenida próxima ao Limeira Shopping, buscar entorpecentes. Os agentes públicos também foram informados de que o veículo se tratava de um GM/Prisma, de placas CDS-0605. Desta forma, os policiais realizaram diligências e lograram encontrar o carro supracitado, que foi abordado em seguida.

Entretanto, quando o veículo parou, o denunciado, que ocupava o banco traseiro do lado direito, abriu a porta e tentou correr, sendo então contido pelos policiais. Em busca pessoal, foram encontrados em poder de JERRY um aparelho celular e quantia de R\$ 50,00.

Em vistoria no interior do veículo, no assoalho do banco traseiro onde o denunciado estava sentado, foi localizada uma porção de cocaína, na forma de "crack". JERRY admitiu a propriedade da droga e afirmou que o motorista do aplicativo Ubernã sabia que ele tinha solicitado a corrida para buscar entorpecente.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 131/139).

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 140/141).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 166/171) e da Defesa (fls. 187/199).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/07, boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 16/18, exame químico-toxicológico (fls. 158/160) e pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Na Delegacia, o acusado disse que chamou um Uber e foi buscar um pouco de droga do tipo crack para entregar a uma pessoa desconhecida e iria ganhar R\$200,00 por isso. Não é vendedor de droga. Chamou o Uber e não falou para o motorista o que iria buscar. Usou o nome de Marcos no pedido. Não quis falar onde iria buscar a droga. Quando voltava com o Uber uma viatura da polícia militar os abordou e encontrou o entorpecente com ele. Já foi preso por tráfico de drogas, cumpriu pena e saiu em fevereiro de 2021 (fls. 07).

Em Juízo, o réu disse que tem 28 anos. Trabalhava como balconista no restaurante e fazia bicos. Chegou do serviço dos seus pais, era por volta das três horas. Costumavam ir no mercado Savegnago. Foram ao mercado e lá fizeram compras. Quando chegou em casa, ajudava seu pai a descarregar o automóvel. Havia acabado de terminar, estava do lado de fora quando veio uma viatura para aborda-lo. Não aceitou a abordagem. Não tinha nada contra a sua pessoa. Mostrou aos guardas que nada tinha e nada devia. A rua estava movimentada. Os guardas insistiram e vieram com força para fazer a abordagem. Pediu calma a sua namorada. Pediu que seus pais fossem chamados. Resistiu a abordagem. Até sua namorada foi ameaçada de ser jogada na viatura porque ela gritava muito. A equipe dos policiais tirou eles de longe dos guardas. Não sabia o que iria ocorrer. Ninguém falou nada de assalto. Seus pais saíram e pediram calma a ele. Ele nada devia. Nada tinha contra ele após a consulta ao sistema. Foi ameaçado por um dos policiais. O policial mexeu no seu aparelho

celular com a sua autorização. Foi dito que eles ainda iriam se encontrar. Mais tarde entrou em contato com João, pessoa que fazia bicos. Pediu a sua esposa que chamasse o Uber do celular dela. Foi até o campo society falar com João para retirar o dinheiro. Era por volta das oito e meia da noite. Ficou por volta de três minutos. Avisou a sua esposa que não o localizou. Falou ao motorista que era rápido. Quando voltava para a sua residência, viu a viatura subindo. Os vidros estavam abertos do Uber. Teria dispensado a droga se tivesse algo em seu poder, eis que viu as viaturas policiais. Quando da abordagem, não sabia o que se tratava. Viu o policial Nadotti e achou tudo aquilo estranho. Não resistiu à ação policial. Não viu o encontro de drogas. Eram duas equipes de força tática com três policiais cada. Não conhecia nenhum dos guardas até então. Tinha cinquenta reais em seu poder. Iria retirar cento e cinquenta reais com João e não o encontrou no local. Havia dois campos de futebol, lá havia mais pessoas. Não conhece a pessoa do Delegado e nem a escrivã que acompanharam o procedimento na delegacia. O cadastro do Uber está em nome de Marcos. Na delegacia nenhum advogado o acompanhou. Desconhece o teor do interrogatório policial. Foi agredido pelos guardas. Falou que as drogas eram dos policiais, eles forjam prisões em Limeira (mídia).

Sua versão lançada em Juízo não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses dele.

O policial militar Nadotti disse que ele e sua equipe estavam em patrulhamento, quando receberam denúncia anônima de que uma pessoa de nome Jerry havia pego um veículo Uber para transporte de drogas em Limeira. Solicitaram buscas próximo ao Limeira Shopping, local apontado na denúncia. Na Avenida Laranjeiras, perto daquele local, viram o automóvel com as placas indicadas. No momento da abordagem, o veículo foi fechado. O réu tentou fugir. Tiveram que usar força física e ele foi algemado. Em busca pessoal localizaram dinheiro e um telefone celular. No interior do veículo, no chão do automóvel onde o denunciado estava, encontraram droga. Indagado, ele disse que recebeu dinheiro para transportar aquela droga, sem informar de onde pegou e para quem iria levar. Ele só disse que pegou no campo society perto do shopping. As escoriações se deram em razão do embate, o réu tentou se desvencilhar, daí o machucado no rosto. Havia abordado o acusado no mesmo dia. Teve uma ocorrência de roubo em um posto de gasolina, as características batiam com a do acusado. A ocorrência foi tumultuada, familiares aglomeraram. Fizeram busca pessoal e nada foi encontrado. Nada tinha contra ele, daí ele foi liberado. Por coincidência caiu outra ocorrência relacionada ao réu, a denúncia era de uma pessoa que mora no mesmo bairro. Na ocorrência do roubo, o acusado ficou muito arredio, passou a gritar para que os familiares o ajudassem, teve entretanto, mesmo assim fizeram a abordagem, até achou que ele era procurado do sistema prisional. O motorista do Uber contou como se deu o trajeto do acusado. O motorista acompanhou as buscas. A denúncia dizia que ele iria buscar a droga perto do Limeira Shopping, as placas e modelo do Uber foram repassados. Foi sua equipe que apresentou o réu ao distrito policial. Não foram até o campo society para verificar se havia mais drogas. Os familiares do acusado chegaram depois na delegacia e passaram a fazer insinuações contra os policiais. O pai do acusado discutiu com o delegado e quase foi detido no distrito policial. As escoriações foram na maçã do rosto e na sobrancelha (mídia).

O policial militar Molina contou que estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de movimentação de drogas. Passaram as características do veículo e das placas, além do envolvimento da pessoa de nome Jerry no transporte. Pediram força a equipe e passaram a patrulhar perto do Limeira Shopping. Viram o Uber descendo no contrafluxo. Fizeram a abordagem. No momento que encostavam, o acusado estava na parte traseira, abriu a porta bruscamente e partiu pra cima da equipe. Fizeram a detenção. Localizou um tijolo de crack no assoalho traseiro. Indagado, o acusado disse que foi buscar a droga no campo society ali perto e ganhou duzentos reais para o transporte. Ele não indicou de quem pegou e nem para quem iria

repassar. Havia participado de uma abordagem envolvendo o réu naquele mesmo dia, era uma ocorrência de roubo de posto de combustível. O réu passou a tumultuar e chamar os familiares. Fizeram busca pessoal, mas nada de ilícito encontraram. Em consulta ao sistema não havia pendências criminais. O motorista do Uber contou que viu o réu entrando e saindo no veículo, mas nada viu de estranho em poder do autuado. Na abordagem da ocorrência de roubo houve tumulto, o acusado estava muito arredio. A notícia chegou via rádio e por isso o abordaram como pessoa suspeita de roubo. A denúncia do Uber foi por telefone, não se recorda o horário. A sua equipe estava em três policiais e havia mais dois guardas, o total era de cinco policiais. O acusado tentou fugir e partiu pra cima deles quando deixou o Uber. Não foram no futebol society pra ver se lá havia mais drogas. O local da abordagem se deu perto de uma rotatória onde há um posto abandonado. Não perderam o réu de vista. Não acompanhou o depoimento do réu e do motorista na delegacia (mídia).

A testemunha Efraim Camargo Santana disse que pegou o passageiro (réu) no bairro Belinho Ometto, não sabe a rua. O acusado pediu pelo aplicativo para que o levasse até um campo society. Ficou aguardando ele ir até o campo de futebol. Lá no campo ele ficou em torno de três a quatro minutos. Depois o acusado retornou ao veículo. Não virou para ver se o acusado estava com algum objeto em seu poder. Depois disso saiu do local, iniciou a rota de volta para o mesmo local do embarque e pouco tempo depois foram abordados por duas viaturas policiais. A ação da polícia foi muito rápida. O passageiro tentou sair do Uber, mas o policial o prendeu na porta do automóvel. Tanto ele como o réu tiveram que deitar no chão. Só se levantou e ficou sentado quando os guardas viram que ele era apenas o motorista do Uber. Explicou a corrida aos policiais. Foi liberado por não ter qualquer envolvimento. Não viu o encontro da droga no banco traseiro. Quando da abordagem policial, já saiu do carro e teve que deitar no chão por ordem dos guardas. Não tinha como visualizar o encontro da droga, o réu estava no banco traseiro, ele teve que se deitar no chão. Não viu nada em poder do acusado quando ele ingressou no veículo no bairro Belinha Ometto e depois no campo society. A abordagem dos policiais se deu na rotatória. Não viu os policiais antes de receber a ordem de parada. As duas viaturas vieram por trás do automóvel. Do local da prisão já foram ao distrito policial, não foram até o campo society. Não tem como abrir a porta do automóvel por fora, só por dentro. O réu tentou fugir da polícia, mas o policial travou a porta com o pé. Não tinha como o réu correr, a ação foi muito rápida. Não conhecia o denunciado. Não se recorda o horário exato da abordagem, acredita que leva em torno de vinte e cinco minutos para ir do bairro Belinha Ometto até o campo society. Na abordagem os policiais disseram que tinham as características do veículo (mídia).

A testemunha de defesa Regiane Pereira da Silva foi ouvida como informante por ser namorada do acusado. Tinha acabado de chegar do serviço. Os policiais foram estúpidos e queriam agredir o réu. Ligou para os sogros, os quais saíram. O réu estava nervoso. Houve abordagem e nada tinha de ilícito em poder dele. Os policiais disseram que iriam se vingar. Na noite, seu namorado foi buscar dinheiro na quadra e eles iriam comprar presente no shopping para o pai. Depois recebeu telefonema da delegacia informando a prisão do réu e nada entendeu. Os policiais contaram que havia uma denúncia de assalto quando da primeira abordagem. O acusado trabalhava de balconista e iria buscar dinheiro. Ele reclamou de ter sido agredido pelos guardas. Ninguém mais sabia que o réu havia chamado o Uber (mídia).

Foram ouvidas testemunhas arroladas pela Defesa.

A testemunha Regiane Pereira da Silva foi ouvida como informante por ser namorada do acusado. Tinha acabado de chegar do serviço. Os policiais foram estúpidos e queriam agredir o réu. Ligou para os sogros, os quais saíram. Seu namorado estava nervoso. Houve abordagem e nada tinha de ilícito em poder dele. Os policiais disseram que iriam se vingar. Na noite, seu namorado foi buscar dinheiro na quadra e eles iriam comprar presente no shopping para o pai. Depois recebeu telefonema da delegacia informando a prisão do réu e não entendeu o que ocorreu. Os policiais

contaram que havia uma denúncia de assalto quando da primeira abordagem. O acusado trabalhava de balconista e iria buscar dinheiro. Ele reclamou de ter sido agredido pelos guardas. Ninguém mais sabia que o réu havia chamado o Uber (mídia).

A testemunha Maria Sônia Andrade do Norte foi ouvida como informante por ser genitora do réu. Não entendeu o entrevisto que ocorreu entre os policiais e o réu. Viu os guardas coagindo seu filho. A ficha policial dele foi puxada. Os policiais queriam bater nele. Convenceu seu filho a colaborar com a abordagem. Os guardas disseram que iriam liberar seu filho, mas que iriam trombar com ele ainda naquele dia (mídia).

A testemunha Jerry Allan foi ouvida como informante por ser genitor do acusado. Havia acabado de chegar do trabalho, tinha ido ao restaurante. Quando descarregou a mercadoria, os policiais chegaram. Tocou o celular da sua esposa e sua nora gritava pedindo ajuda deles. Chegou lá e os policiais pediram para eles ficarem longe. Não foi explicado o motivo da abordagem. A raiva do seu filho com aquilo tudo era enorme. Questionaram o porquê da abordagem policial e nada foi dito. Depois foi saber que era uma abordagem envolvendo um delito de roubo. Estranhou a ação dos guardas. No final da abordagem ouviu do policial Nadotti que seu filho tinha escapado, mas mais tarde ele seria pego. Foi para a delegacia e lá discutiu com o delegado, achou estranho o que ocorreu com o seu filho. Seu filho trabalhava de atendente no restaurante (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima informando que uma pessoa de nome Jerry se deslocou do bairro Belinha Ometto até as proximidades do Limeira Shopping para buscar drogas. O meio de transporte seria pelo aplicativo Uber, com as características do automóvel repassadas.

Em diligências pela região indicada os policiais viram o veículo mencionado. Nas proximidades de uma rotatória, o automóvel foi fechado pelas viaturas policiais. O réu tentou fugir, sem sucesso, eis que detido pelos militares, havendo resistência. Em busca pessoal foram localizados dinheiro e um telefone celular.

Ao realizarem revista no interior do automóvel, junto ao local onde o réu estava sentado, os policiais encontraram uma porção de cocaína, na forma de "crack", pesando 1.020,76 gramas de cocaína na forma de crack.

Indagado pelos policiais, ele confirmou a traficância. Em solo policial ele confessou o delito à autoridade policial.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade e a natureza da droga (cocaína, na forma de "crack"), as circunstâncias da prisão, a delação anônima e os antecedentes criminais específicos, assim como o depoimento incriminador dos policiais militares e a confissão extrajudicial, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia -

Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Após todo o processado não se extrai qualquer razão lógica e plausível de suposta armação dos guardas para incriminar o acusado, de modo a apontá-lo injustamente como sendo autor do grave delito de tráfico de drogas.

Difícil imaginar que policiais militares de Limeira desperdiçaram seu precioso tempo e criaram uma estória fantasiosa para ser trazida à Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, forjando provas e plantando drogas, para acusar o réu, que seria pessoa inocente e sem qualquer envolvimento com a traficância ilícita. É absurda essa situação.

Já se ouviu nos jornais e noticiários que algum agente de segurança pública foi preso ou condenado pelo cometimento de algum delito, o que, à primeira vista, retira a fé daqueles servidores (policiais e guardas) que se empenham no dever constitucional de manter a segurança pública.

Todavia, deve ser levado em consideração que a exceção não é a regra e a grande maioria dos policiais militares são pessoas honradas, de boa-fé, dedicados a combater o crime, com inúmeros sacrifícios pessoais, familiares e com risco de morte.

Portanto, a prova oral acusatória convence e fica acolhida, cabendo lembrar que as

testemunhas de defesa foram ouvidas como informantes, não tendo presenciado os fatos criminosos descritos na denúncia.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são desfavoráveis ao réu, devendo a pena-base partir acima do mínimo legal, considerando a substancial quantidade de droga apreendida (1.020,76 g de cocaína na forma de crack), assim como os maus antecedentes (autos nº 0009346-68.2012.8.26.0320 - fls. 34/35), de modo que elevo a pena em 1/5, fixando-a em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, utilizo a outra condenação do acusado, pela qual é reincidente específico (autos nº 0019386-07.2015.8.26.0320 - fls. 35), para elevar a pena em mais 1/6, isto é, 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal

Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente específico, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição quanto ao acusado.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao crime de tráfico, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado em razão da reincidência específica, considerando inclusive o posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no acórdão proferido no HC n.º 118.553/MS.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar IAGO MATHIAS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, no valor, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol do culpado.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

P.R.I.

Limeira, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA